

1501467-54.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... estável e permanente para a prática de tráfico de drogas no local, sendo Região com alta incidência de registros policiais relacionados ao tráfico de drogas e furto residenciais praticados por usuários de entorpecentes.

WALTER responsável pela venda das porções preparadas e fornecidas por MICHEL em sua residência.

Ocorre que policiais civis realizaram diligência velada e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501467-54.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259670/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 20422601 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 157/21/591 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 2259670 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL RENAN DOS SANTOS e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel (Def.Walter), e dr. Holmes Nunes Júnior (def.Michel). Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) MICHEL RENAN DOS SANTOS E WALTER ROMÃO DE OLIVEIRA, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Celso Lino de Oliveira e Gabriel Vasco de Toledo.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Celso e Gabriel) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s) (Michel e Walter).

Pelas partes foi dito que desistem do laudo de degravação dos celulares.

Pelo dr. Holmes Nunes Júnior foi dito que, por motivo de foro íntimo, renuncia neste ato à defesa do réu Michel nestes autos.

Pelo réu Michel foi dito que tomou ciência da renúncia do dr. Holmes e requer que a Defensoria Pública atue em sua defesa a partir da sentença.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação ao laudo de degravação dos celulares.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, WALTER ROMÃO DE OLIVEIRA e MICHEL RENAN DOS SANTOS estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta até por volta de 16h50min do dia 22 de setembro de 2021, notadamente no bairro Paulista, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, WALTER ROMÃO DE OLIVEIRA, qualificado e indiciado às fls. 06/07, 24 e 38, e MICHEL RENAN DOS SANTOS, qualificado e indiciado às fls. 08, 22 e 37, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta, ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta de 16h50min, na Rua Marquês de Monte Alegre, n.º 1.048, Bairro Paulista, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, WALTER ROMÃO DE OLIVEIRA, qualificado e indiciado às fls. 06/07, 24 e 38, e MICHEL RENAN DOS SANTOS, qualificado e indiciado às fls. 08, 22 e 37, atuando em conluio e com unidade de desígnios delituosos, traziam consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 1,4g (um grama e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, os denunciados se associaram de forma estável e permanente para a prática de tráfico de drogas no local, sendo Região com alta incidência de registros policiais relacionados ao tráfico de drogas e furto residenciais praticados por usuários de entorpecentes.

WALTER responsável pela venda das porções preparadas e fornecidas por MICHEL em sua residência.

Ocorre que policiais civis realizaram diligência velada e presenciaram a movimentação característica de mercancia ilícita: WALTER atendia usuários na via pública e depois se dirigia até a residência de MICHEL, que o aguardava no portão. Diante do visível estado de flagrante, os investigadores abordaram WALTER e, em sua posse, localizaram 07 (sete) invólucros de cocaína e R\$66,00 (sessenta e seis) reais. Ato contínuo, MICHEL, que presenciava a ação, fechou o portão da casa para dificultar a abordagem policial e sinalizou para outros residentes da casa entrarem - certamente para se livrarem dos ilícitos. Cerca de cinco minutos depois, o portão foi aberto e a casa vistoriada, mas nenhuma droga foi encontrada.

WALTER disse que, há cerca de quatro meses, vende drogas no local juntamente com MICHEL, pelo que recebe 03 (três) porções a cada kit vendido (fls. 03/05 e 06/07). O denunciado MICHEL ficou silente (fls. 08).

O exame pericial constatou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto fls. 12/13 e laudos fls. 18/20 e 110/112).

As circunstâncias da prisão, a visualização de movimentação típica de mercancia ilícita, a atuação dividida em tarefas para evitar a repressão policial, a confissão e detalhamento do conluio por parte de WALTER e a apreensão de porções de cocaína e dinheiro em espécie tornam certo que os denunciados, associados com ânimo de estabilidade e permanência, traziam consigo os entorpecentes com a finalidade de

comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Gabriel Vasco de Toledo – Policial Civil – narrou que verificava notícia de tráfico e acompanhou movimentação típica de tráfico de drogas. Em dado momento, VALTER se afastou e foi abordado. Eles pegavam coisas da janela da casa na frente da qual estavam sentados. Com VALTER, encontrou sete porções de cocaína. A abordagem foi em uma rua transversal ao local da campana. O outro rapaz viu a abordagem e tentou deixar o local. O policial Celso foi atrás e o abordou. Depois, eles assumiram o tráfico de drogas e WALTER falou que trabalhava para o outro abordado. Os dois réus entregavam, revezando-se, sem muita ordem, objetos para motoristas de carro. A casa na qual pegavam coisas, era logo após a casa de esquina. Com MICHEL nada foi encontrado. Não sabe se alguém entregava na casa as drogas para os réus, mas na casa estavam o irmão e a companheira de MICHEL. WALTER disse que vendia droga há pouco tempo para MICHEL e que ganhava entorpecente em troca, já que seria usuário. Celso Lino de Oliveira – Policial Civil – disse que receberam denúncias de tráfico no local, fizeram campanas e viram os réus, cujas características físicas (moreno gordo, que seria o MICHEL, outro alemãozinho, WALTER) coincidiam com eles. Viu que MICHEL pegava algo na casa e passava para WALTER, que entregava a consumidores. WALTER deixou o local por instantes e foi abordado. Com ele, sete porções de cocaína. MICHEL viu a abordagem e foi perseguido e detido. Mas antes, MICHEL conseguiu entrar na casa e o policial viu que houve movimentação interna, talvez para a dispensa de drogas. WALTER assumiu que traficava para MICHEL. Tanto MICHEL quanto WALTER ficaram do lado de fora da casa. MICHEL pegava drogas na janela da casa e entregava para WALTER. Quando MICHEL fugiu e entrou na casa, ele trancou o portão para impedir o acesso dos policiais. Apenas depois de um tempo, é que o portão foi aberto.

Interrogado, WALTER confessou os fatos. Disse que recebia drogas de MICHEL e entregava drogas a motoristas. Fazia quatro semanas que fazia isso. Ganhava três porções de cocaína por dia. O dinheiro não era produto de tráfico. Tinha ido comprar um carregador para a mulher de MICHEL e estava voltando quando foi abordado. A droga apreendida tinha comprado. MICHEL não tinha nada a ver com o tráfico, mas o interrogando vendia na frente da casa dele.

MICHEL negou os fatos. Disse que tinha apenas cheirado pó com o menino (WALTER) e pedira para ele buscar um carregador. Quando o interrogando chegou à esquina foi abordado. O policial entrou em sua casa usando da chave que o interrogando trazia no bolso. Não sabe se WALTER vendia drogas em frente a sua residência.

Não há dúvidas sobre o tráfico de drogas: Os policiais receberam denúncias de tráfico no local, fizeram campanas e viram os réus, cujas características físicas (moreno gordo, outro alemãozinho) coincidiam com eles. Viu que MICHEL pegava algo na casa e passava para WALTER, que entregava a consumidores. WALTER deixou o local por instantes e foi abordado. Com ele, sete porções de cocaína. MICHEL viu a abordagem e foi perseguido e detido. A ação delitiva foi flagrada pelos policiais. Ambos os réus foram vistos pelos policiais na prática do tráfico de drogas. Restou comprovado o delito de associação para o tráfico de drogas, já que eventual vínculo associativo entre os réus ficou claro. WALTER confirmou que vendia drogas associado com MICHEL há quatro semanas. Havia divisão de tarefas. WALTER entregava drogas a motoristas. MICHEL entregava as drogas a WALTER. E combinados e dividindo funções realizavam o tráfico de drogas no local há pelo menos um mês. Depois WALTER tentou retratar-se da delação, sem fundamento. Há ainda a narrativa dos policiais dizendo WALTER afirmara vender drogas em conjunto com MICHEL há algum tempo. Tudo a demonstrar que a delação inicial deve ser mantida.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à

venda. No ponto: " A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011). Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10)

Da dosimetria da pena

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 42/50 e 51/55): MICHEL RENAN DOS SANTOS é portador de maus antecedentes -condenado por tráfico de drogas nos autos n.º 0005064-50.2010.8.26.0451 (pena extinta em 03.02.2012) - e WALTER ROMÃO DE OLIVEIRA é primário.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Não há como se olvidar que WALTER disse traficar drogas com MICHEL há algum tempo, o que demonstra a associação criminosa, habitualidade e dedicação à atividades criminosas.

As circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

E mais, cabe destacar que o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas instituiu o denominado tráfico privilegiado a prestigiar o princípio da individualização da pena, tendo por objetivo diferenciar as penas impostas ao traficante eventual e àquele que habitualmente se dedica à atividade criminosas.

E nessa seara, após longa discussão doutrinária e jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, reconheceu que a figura do "tráfico privilegiado de drogas", contida no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, não ostenta natureza hedionda, sendo, posteriormente, acompanhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar o enunciado de sua súmula nº 512.

O privilégio tem o condão de diminuir a pena de um a dois terços e demanda a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam, a i) primariedade e ii) e bons antecedentes do agente, a iii) não dedicação a atividades criminosas e, por fim, iv) não integração de organização criminosa. Na ausência de um destes elementos inviabiliza-se o reconhecimento da causa de diminuição.

No tocante ao requisito da dedicação a atividades criminosas, tem-se que alguns fatores podem denotar habitualidade e envolvimento no crime, impedindo o

reconhecimento da figura privilegiada.

Exemplo disso é a constatação de que o réu tinha grande quantidade e diversidade de drogas.

Ora, as circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

É o que permite o art. 42 da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada parcialmente procedente a presente ação penal, condenando-se os réus WALTER ROMÃO DE OLIVEIRA e MICHEL RENAN DOS SANTOS como incurso nos artigos 33, caput, 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s) Walter, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Walter Romão de Oliveira foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 121-123), desde data incerta até por volta de 16h50 do dia

22 de setembro de 2021, notadamente no bairro Paulista, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Walter e Michel Renan dos Santos associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Consta, ainda, que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta de 16h50, na rua Marquês de Monte Alegre, n.º 1.048, Bairro Paulista, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Walter e Michel, atuando em conluio e com unidade de desígnios delituosos, traziam consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 1,4g (um grama e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, os réus se associaram de forma estável e permanente para a prática de tráfico de drogas no local, sendo Walter responsável pela venda das porções preparadas e fornecidas por Michel em sua residência. Ocorre que policiais civis realizaram diligência velada e presenciaram a movimentação característica de mercancia ilícita: Walter atendia usuários na via pública e depois se dirigia até a residência de Michel, que o aguardava no portão. Diante do visível estado de flagrante, os investigadores abordaram Walter e, em sua posse, localizaram 07 (sete) invólucros de cocaína e R\$66,00 (sessenta e seis) reais. Ato contínuo, Michel, que presenciava a ação, fechou o portão da casa para dificultar a abordagem policial e sinalizou para outros residentes da casa entrarem – certamente para se livrarem dos ilícitos. Cerca de cinco minutos depois, o portão foi aberto e a casa vistoriada, mas nenhuma droga foi encontrada.

Interrogado em solo policial, o réu Walter disse que: “assume a propriedade do entorpecente. Fazia a venda das substâncias encontradas em seu poder (cocaína) ao preço de R\$10,00. Há cerca de 4 meses, começou a vender entorpecentes para a pessoa de Michel Renan dos Santos, morador da rua Marques de Monte Alegre, 1048, Paulista. Independente da quantia de entorpecente que comercializa, recebe três pinos de cada kit vendido (total de 13) ao final do "expediente". 10 pinos eram lucro do Michel. que vendia cerca de 130 pinos por noite. Na data de hoje, tinha em seu poder 7 pinos, quando foi abordado por policiais civis desta delegacia. Ainda não tinha vendido nenhum entorpecente, mas que já havia recebido tal quantia fracionada e pronta para o consumo da pessoa de Michel. Chegou a atender alguns "clientes", mas ainda não tinha feito a entrega da droga. Em seu poder, também foi encontrada a quantia de R\$ 66,00, de Michel” (fls. 6-7).

O réu Michel Renan dos Santos exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 8).

Celso Lino de Oliveira, policial civil, narrou que: “na data de hoje, por volta das 16h50, tinha como componente de equipe o também Policial Civil Gabriel, e após campanha realizada no endereço dos fatos (numeral 1048), visualizou o agora indiciado Walter Romão de Oliveira, que trajava camiseta branca e bermuda cor de laranja, realizando a venda de entorpecente a motoristas e transeuntes. Após perceber esta movimentação característica de tráfico de entorpecentes, Walter se distanciou do local onde pegava entorpecente antes da venda, quando a equipe resolveu abordá-lo. Ao perceber a abordagem, o indivíduo que estava na frente da residência, segurou o portão da residência. Toda a ação, foi acompanhada pela equipe, dando a entender que a droga era guardada naquela casa, pela janela de um dos quartos. O morador da residência, agora identificado por Michel Renan dos Santos, percebeu a abordagem de Walter, tentando adentrar rapidamente ao interior do imóvel, sendo abordado no portão, ocasião em que tentou impedir a entrada dos Policiais, e que nenhuma droga foi localizada no interior. Na casa havia outros moradores que entraram rápido com a chegada da polícia, e através de sinais, Michel mandou um sinal para que os filhos entrassem, o que levou o entendimento da equipe de que estariam escondendo ou se desfazendo de produto ilícito, já que demoraram cerca de 5 minutos para abrirem o portão. Na abordagem de Walter, ele veio a confirmar tal prática, ou seja, que adquiria o entorpecente (cocaína) da casa de Michel, e ambos na calçada vendiam entorpecente. Em poder de Walter, foi encontrada 7 trouxinhas (plástico) de substância análoga à cocaína. Walter assumiu a propriedade das drogas, dizendo que as teria adquirido para a venda da pessoa de Michel Renan dos Santos. Foi dado voz de prisão aos indiciados, sendo submetidos ao

exame de corpo de delito e encaminhado à Cadeia competente" (fls. 3-4).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial civil Gabriel Vasco de Toledo (fls. 5).

Às fls. 52, juntada certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

Às fls. 188-201, manutenção da negativa de ANPP.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12-13, fotografia de fls. 14, laudo de constatação de fls. 18-20, laudo de exame definitivo de fls. 125-127.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvido o policial civil Gabriel Vasco de Toledo. Estava apurando com o policial Celso uma denúncia de tráfico. Observaram que eles entregavam algo a carros e também que pegavam algo de uma janela de uma casa. Ficaram ao menos 30 minutos em observação. Abordaram Walter e com ele havia 7 porções de cocaína. O outro rapaz estava vindo de uma casa, viu os policiais e retornou. Celso foi atrás dessa pessoa. Em conversa, os dois assumiram a traficância e Walter disse que trabalhava para Michel. Ambos faziam as entregas, cada hora um. Entregavam algo a motoristas de carro. A janela era a lateral da casa de um deles. Era uma casa logo após a casa de esquina. Na esquina, fica um comércio. Walter foi abordado na Rua Benjamin Constant, que não é a rua da casa, mas sim a rua da janela. Com Michel não foi localizada nenhuma droga. Conhecia Michel porque ele já tinha sido preso pela equipe da delegacia de homicídios; não conhecia Walter. A denúncia foi recebida pelo policial Celso, que apenas lhe disse que era uma denúncia de tráfico que iam apurar. Perguntado pelo Ministério Público, disse que não souberam dizer quem passava as drogas pela janela para Michel e Walter. Depois viram que um irmão e a esposa de Michel estavam na casa. Ambos entregavam drogas aos carros. Walter lhe disse que fazia pouco tempo de estava atuando com Michel e que recebia seu pagamento em drogas. Acredita que Michel seja um viciado.

b) Em seguida, ouvido Celso Lino de Oliveira, policial civil. Relatou que recebeu denúncias anônimas de que estava ocorrendo tráfico na rua Marques de Monte Alegre, quase na esquina com a Rua Benjamin Constant. Ficaram de campana com viatura descaracterizada. Havia um "moreno gordo" (Michel) e um "alemãozinho" (Walter). Michel ia até a janela, pegava algo, entregava a Walter que, por sua vez, entregava aos carros. Depois de um tempo, Walter foi a uma loja, os policiais saíram do local da campana e abordaram Walter. Com ele, localizaram 7 pinos de cocaína. Michel estava observando da esquina e retornou a sua casa. Michel conseguiu entrar em casa e fechar o portão antes que o depoente o encontrasse. Houve uma correria dentro de casa enquanto isso, acredita que para eliminar a droga. Walter disse a eles que trabalhava para Michel. Com Walter, nada foi localizado. Depois, Michel deixou entrarem em sua casa, mas não localizaram nada ali. O banheiro tinha sinal de descarga. Não localizaram dinheiro com nenhum dos réus. Conhecia Michel, que tinha sido preso por tráfico por outra equipe. Walter mora 2 ou 3 casas distantes da de Michel.

c) Interrogado o réu Walter Romão de Oliveira. Confirmou que estava traficando cocaína. É verdade que Michel lhe entregava as drogas e ele entregava aos motoristas. Não fazia muito tempo que estava vendendo drogas, umas 4 semanas. Ganhava 3 pinos de cocaína por dia para fazer esse trabalho. É usuário, cheirava a droga que recebia. Era Michel que lhe entregava a droga para vender. O dinheiro que estava com ele tinha sido entregue por Michel para que ele comprasse um carregador de celular para a esposa dele. Não tinha vendido nada ainda no dia, apenas tinha cheirado um pino com Michel. Tinha ido comprar o carregador de celular e, na volta, foi abordado pelos policiais. O dinheiro que estava em sua posse era o troco, Michel tinha dado 100 reais e ele pagou 30 reais no carregador. Depois começou a dizer que Michel não lhe fornecia drogas e que a droga não era de Michel. Michel pegava da janela água e salgado. Michel era seu amigo e ficava bravo por ele traficar em sua porta.

d) Por fim, ouvido o réu Michel Renan dos Santos. Alegou que não estava traficando. Tinha cheirado um pino de cocaína com Walter e pediu a ele que comprasse um

carregador de celular para a sua esposa. Estava voltando para casa, foi abordado pelo policial Celso que lhe revistou e pegou a chave de sua casa. Não deu sinal para nenhum irmão. Era seu filho de 14 anos. O policial Celso estava com a arma apontada para a sua cabeça, e mandou o filho entrar na casa para não ver a cena. O policial entrou na sua casa, revirou tudo, não achou droga. Levou-o para a delegacia e voltou de novo para a sua casa. Não sabe se Walter vendia drogas. É usuário de cocaína, mas não é viciado. Conhece o policial Celso porque já o abordou antes e ele foi preso como usuário de drogas.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decreta sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO: ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO
Impõe-se reconhecer que o conjunto probatório é frágil e não se demonstra apto a sustentar uma condenação criminal quanto ao delito de associação para o tráfico. Isso, porque extrai-se dos autos que em desabono do acusado restaram apenas relatos genéricos dos policiais responsáveis pela prisão. Nada em concreto foi produzido, não há nenhuma informação segura acerca da estabilidade e permanência, tal como prevê o artigo 35, caput, da Lei de Drogas.

Ao contrário, os agentes apenas teriam visualizado movimentação característica de tráfico de entorpecentes, sem, contudo, realizarem nenhuma diligência prévia apta a confirmar as suspeitas. Não foi requisitada a expedição de nenhum mandado de busca e apreensão para a residência do réu Michel, não há imagens dos fatos, sequer há informações sobre o lapso temporal de atuação do réu. Tudo em virtude da ausência de dados coletados pelos policiais.

Cumprе salientar que o crime em questão não se tipifica com a ocorrência de concurso eventual de pessoas em atuação transitória ou ocasional. Para a concretização deste tipo penal é necessário o vínculo estável entre os agentes para a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei no 11.343/06. Exige-se, pois, a demonstração inequívoca de estabilidade e permanência.

Neste sentido observou Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi que "[...] haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária a prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria [...]" (Lei de Drogas Anotada: Lei no 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2006).

Na mesma linha é o posicionamento de Renato Marcão, no sentido de que, para a

configuração do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, "[...] é necessário que a associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na 'societas criminis', que não se confunde com mera coautoria" in "Tóxicos", Saraiva, 4ª edição, p. 281).

Desse modo, observa-se que, no caso em análise, não ficou evidenciado o liame subjetivo de caráter estável e permanente entre os acusados. Não há nada que assegure a existência do animus associativo ou a duradoura atuação em comum. Nesse diapasão, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os pacientes e os integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; na verdade, as instâncias de origem presumiram, com base apenas no local em que os réus foram presos em flagrante, que eles seriam integrantes do Comando Vermelho e, assim, proclamaram a condenação destes com base em meras conjecturas acerca de uma societas sceleris. 3. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva? o ânimo a mover a conduta? decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 4. Uma vez afastada a condenação dos pacientes pelo crime de associação ao tráfico e porque eles são tecnicamente primários, possuidores de bons antecedentes e não há, nos autos, elementos concretos a evidenciar sua dedicação a atividades delituosas ou integração a organização criminosa, deve ser aplicada, em favor, dos dois a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Como consectário da redução efetivada na pena dos acusados, deve ser feito o ajuste no regime inicial do seu cumprimento das respectivas penalidades para o semiaberto, pois, apesar de terem sido condenados a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, serem tecnicamente primários ao tempo do delito e, possuidores de bons antecedentes, tiveram a pena-base estabelecida acima do mínimo legal. 6. Ordem concedida, para absolver os pacientes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicá-la no patamar máximo de 2/3. (HC 596.389/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021 - grifos nossos).

Assim, conclui-se que a prova colhida é frágil e indiciária para justificar o decreto condenatório: a apreensão de drogas em poder do acusado se mostrou insuficiente para demonstrar participação em um crime de associação.

Portanto, com base no princípio in dubio pro reo, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de

Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a média de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida do acusado não é excessiva, corroborando as declarações do acusado no sentido de que é usuário.

Isso posto, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não tendo sido demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a

desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição, tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional por ferir o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344). Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, fixada tal premissa, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas. Isso posto, diante da alegação ora invocada, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, afastando-se a imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas, o que torna imperiosa a sua absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Porém, rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: o réu é primário e as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há que se reconhecer a confissão, ainda que apenas a informal e mesmo que a pena não sofra alteração.

c) Da aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo. Processos em curso não são aptos a afastar o benefício e, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto. Caso o privilégio seja reconhecido, requer seja fixado regime aberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus